

1500991-70.2021.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... e, subsidiariamente, a desclassificação de tráfico para porte de drogas para consumo próprio, o reconhecimento de tráfico privilegiado, a substituição da pena corporal por restritivas de direito e a fixação de regime inicial em meio aberto (fls. 249-258).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ausentes preliminares ou causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1231 1500991-70.2021.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500991-70.2021.8.26.0581

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2233392/2021 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 19882027 -

DEL.POL.SÃO MANUEL, 1170/21/211 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 2233392 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR SILVA DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO GABRIEL CEMIN MARQUES

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou GILMAR SILVA DA CRUZ, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, no dia 26 de agosto de 2021, por volta das 12h30min, na Rua Luiz Cella, nº 60, área rural, nesta cidade e Comarca de São Manuel, o réu supostamente guardava 04 (quatro) pinos de cocaína, com peso líquido total de 0,86 gramas, e 03 (três) porções de maconha, com peso líquido total de 4,28 gramas, substâncias que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, além de 11 (onze) maços de cigarro da Marca Eight, 01 (um) caderno modelo espiral com anotações, 100 (cem) embalagens plásticas, 03 (três) aparelhos de celular, 01(um) aparelho DVR, 01 (um) saco plástico e R\$744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) em notas e moedas

diversas.

Segundo a exordial acusatória, o réu é conhecido dos meios policiais pela prática contumaz do delito de tráfico de entorpecentes. No dia dos fatos, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais se dirigiram até a residência do réu e adentraram no recinto. Em buscas realizadas no interior do bar, logrou-se êxito em encontrar dentro de uma bolsinha, quatro pinos de cocaína e três porções de maconha, todas embaladas individualmente e prontas para a venda. Ato contínuo, foram encontrados maços de cigarro de origem estrangeira. Na sequência, os policiais subiram para a residência do denunciado, onde encontraram no interior de um galão de água a quantia de R\$471,00, em notas de papel variadas. Em seguida, encontraram outro recipiente contendo R\$273,00 em moedas.

O réu foi preso em flagrante (fl. 06).

Decisão de fl.39 determinou a redistribuição do feito à 1ª Vara Criminal de São Manuel, por dependência aos autos sob n.º 1500984-78.2021.8.26.0581.

Declinou-se da competência, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal (fls.67/69).

O juízo federal, por sua vez, declarou extinta a punibilidade do crime federal e reputou-se incompetente (fls.98/100).

Decisão de fls. 101/103 homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva.

Mandado de prisão cumprido às fls.112/114.

Em sede de habeas corpus (fls. 122/128), foi determinada a soltura do réu, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Alvará de soltura cumprido às fls. 140/143.

Notificado à fl. 168, o réu apresentou defesa prévia às fls. 162/165.

Recebida a denúncia em 19/10/2021 (fl.169), ocasião em que designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 231-232) foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, a d. representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição do réu por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a desclassificação de tráfico para porte de drogas para consumo próprio, o reconhecimento de tráfico privilegiado, a substituição da pena corporal por restritivas de direito e a fixação de regime inicial em meio aberto (fls. 249-258).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ausentes preliminares ou causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06); termos de depoimentos (fls.07/09); interrogatório do acusado na fase policial (fls. 10/11); auto de exibição e apreensão (fls. 12/14); boletim de ocorrência n.º 1170/2021 (fls. 15/17); laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 43/48) e definitivo (fls. 156/158); relatório final do inquérito policial (fl. 117/118); bem como a prova oral colhida na audiência de instrução e julgamento.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (maconha e cocaína) se encontram expressamente previstas na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

No entanto, é importante consignar que, além da comprovação da materialidade e da autoria do fato, faz-se necessário analisar a responsabilidade criminal do acusado, no que se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto pelo art. 52, inciso I, da Lei n. 11.343/03, que enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente, a fim de que possa distinguir a aquisição de droga para uso ou para o tráfico.

No mesmo sentido, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, contempla alguns parâmetros para se determinar se a droga se destinava ao uso pessoal do agente.

Destarte, dispõe o dispositivo em comento que: "para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No presente caso, considero que não houve prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório de que a substância entorpecente seria destinada a mercancia ilícita e não ao simples uso.

Vejamos:

A testemunha Claudio Aparecido Leme, policial civil, declarou que houve uma operação conjunta da Polícia Civil e Militar de um mandado de prisão e de busca em desfavor do réu. Disse que o réu é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas na região; que na casa do réu foram encontradas drogas, maços de cigarro e valores fracionados. ;que foi realizada busca nas imediações da residência do acusado e nada foi encontrado; que há algum tempo o setor de inteligência da polícia recebia denúncias acerca de tráfico de drogas realizado pelo acusado; que o réu tem um bar, que se localiza em um sobrado, e o tráfico é realizado na parte de baixo do bar; que o réu reside no imóvel em que se situa ao bar; que as denúncias chegam de diversas formas; que o mandado de busca foi requerido pelo delegado de polícia da Comarca; que trabalharam no mínimo 10 policiais na operação; que a droga estava embalada e que o dinheiro era picado.

A testemunha Daniel Aparecido Nespeque, policial militar, aduziu que estava de serviço e foi informado que deveria prestar apoio à Polícia Civil para fins de cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do réu; que ingressaram na residência do réu onde também funcionava um bar; que o policial Cláudio encontrou porções de cocaína e maconha em uma bolsinha; que também foram encontrados valores fracionados no local; que nas imediações da residência do acusado foram realizadas buscas, onde foram encontrados pelos cães farejadores resquícios de droga; que tem conhecimento de que o réu já foi preso por tráfico de drogas; que a busca foi realizada em um pasto localizado cerca de quinhentos metros da residência do réu; que havia populares acompanhando a operação policial, mas que não sabe se houve condução de testemunhas civis até a delegacia; que não recorda se a esposa do réu foi algemada, mas que ela foi conduzida para a delegacia.

A esposa do acusado, Karen Monique Pereira Moreira, em juízo, disse que estava com o réu no horário do almoço quando os policiais chegaram apontando arma e mandando que não se movessem; que os policiais queriam bater nos seus cachorros, momento em que informou que eles eram mansos; que Gilmar foi algemado sob a justificativa que o mandado se tratava de uma dívida de pensão. Posteriormente, outro policial falou que a prisão seria realizada porque foram encontrados pinos de cocaína e maconha no bar. Negou a existência da droga no local. Que os policiais perseguem o seu marido; que o caderno se tratava de anotações relativas ao movimento do bar; que foram separados na abordagem e na delegacia como forma a coagir o réu a confessar; que o dinheiro se refere aos fiados do bar e demais pagamentos devidos pelos clientes do estabelecimento; que o dinheiro era fracionado em decorrência dos pagamentos recebidos; que os policiais que prenderam os réus foram os mesmos de outra ocorrência em que o réu restou absolvido.

A testemunha Pablo Ocana Ramos Cordeiro, em juízo, disse que quando chegou o réu já estava dentro de uma viatura e a esposa Karen estava algemada; que os policiais não deixaram ninguém se aproximar; que no local funciona um bar; que nunca ouviu falar de tráfico de drogas no bar do réu.

O réu, na ocasião de seu interrogatório, disse que os policiais foram até sua casa e que estava no segundo andar com sua esposa; que os policiais quebraram o portão de sua residência e o abordaram informando que havia um mandado de prisão por dívida de pensão. Após, os policiais adentraram ao bar e voltaram com as drogas. Negou a existência das drogas. Que foi algemado juntamente com sua esposa; que os policiais ameaçaram prender sua esposa caso não assumisse a posse das drogas; que somente soube a quantidade de drogas quando já estava preso; que ficou com medo na delegacia; que é perseguido pela polícia que tenta incriminá-lo; que sempre é abordado e que a polícia nunca encontra nada com o réu; que o dinheiro encontrado

no local é decorrente dos pagamentos recebidos pelos clientes do bar e o caderno se refere a anotações do estabelecimento; que no terreno próximo à sua casa não foi encontrado nada; que no seu bar tem mesa de sinuca, fliperama e que há movimento de pessoas no bar, porém nunca viu tráfico de drogas próximo ao seu bar; que possui duas filhas menores de idade; que ajuda as filhas com R\$ 300,00 a R\$ 400,00 reais e compra itens básicos necessários; que fatura cerca de R\$ 6.000,00 com o bar; que se sente perseguido pelos policiais civis e que o policial Bola disse que se o réu se safasse neste processo iria dar "um jeito" no réu; que na delegacia os policiais disseram para o réu confessar para não complicar a sua esposa; que depois que foi solto os policiais passaram algumas vezes em frente ao seu bar olhando para o réu; que no dia da operação havia muitos populares no local.

Pois bem.

Do que se pode observar dos depoimentos dos policiais que abordaram o acusado, com destaque para as declarações do policial civil Claudio Aparecido Leme, as drogas foram encontradas na residência do réu em pequena quantidade, conforme bem asseverou o E. STJ quando do julgamento do HC nº 696256 (fls. 122-128), sendo que o investigador intuiu que a quantia de R\$ 744,00, cigarros supostamente contrabandeados e um caderno de anotações seriam suficientes a caracterizar o delito de tráfico de drogas.

Cumpra dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento.

Com efeito: "São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha." (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017).

Ocorre que o réu instalou um bar no primeiro andar de sua residência, fato que justifica a presença do caderno de anotações referentes a controle de vendas do bar, conforme alegaram o réu e sua esposa, de modo que, à míngua de outros elementos trazidos pelos agentes durante a investigação, não é possível concluir que as drogas se destinavam à mercancia ou para uso pessoal.

Importante frisar que os policiais afirmaram que haviam diversas pessoas no local, contudo, nenhuma delas foi identificada e arrolada para confirmar se no local havia venda de drogas. Por outro lado, a testemunha Pablo Ocana Ramos Cordeiro afirmou ser cliente do bar e nunca ouviu qualquer boato de que no local funciona um ponto de venda de drogas.

Note-se que a quantidade de entorpecente (0,86 gramas de cocaína e 4,28 gramas de maconha) não é incompatível com a tese de porte para consumo apresentado pela defesa técnica e a quantia encontrada no local restou devidamente justificada pelo fato de o réu ter instalado um bar em sua residência, não se mostrando o valor apreendido (R\$ 744,00) incompatível com o faturamento inerente a atividade comercial exercida.

Ademais, consigno que inexistem outros elementos de prova suficientes a caracterizar a traficância por parte do réu, eis as investigações não foram aprofundadas pela autoridade policial, esgotando-se na apreensão de pequena quantidade de drogas em uma bolsinha que estava no domicílio do réu, não sendo possível, assim, afastar a tese de as drogas foram adquiridas pelo réu para consumo próprio.

Por todos estes fatores, conclui-se não haver, no caso, provas seguras o suficiente acerca do destino da droga ao comércio, que permitiria a condenação com fulcro no artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/2006.

Logo, em havendo dúvida sobre a tipificação do fato, ante a insuficiência do conjunto probatório, cabe ao julgador conferir a interpretação que se afigure mais benéfica ao acusado, como corolário do "in dubio pro reo".

Nesse sentido, o TJ-SP:

"TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO - PORTE PARA USO PRÓPRIO - ADMISSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS SEM QUALQUER OUTRO ELEMENTO A INDICAR A MERCANCIA OU OUTRO ATO DE TRÁFICO - RECURSO PROVIDO. "Na dúvida, necessária a desclassificação, ainda que com isso esteja-se correndo risco de brindar imerecidamente aquele que, pela realidade desconhecida, merecia a condenação pelo tráfico." (TJ-SP - APR:

15003017920218260439 SP 1500301-79.2021.8.26.0439, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 14/03/2022, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/03/2022)

"Tráfico de entorpecentes. Apreensão de pequena quantidade de droga, compatível com a destinação ao uso próprio, em poder de pessoa suspeita de dedicação ao tráfico. Desclassificação operada. A condição de traficante não exclui a de usuário.

Apreendida pequena quantidade de entorpecente, sem demonstração alguma de que aquela droga se destinasse ao tráfico, mostra-se imperiosa a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas, ainda que haja indícios de que o réu se dedique ao tráfico. Traficantes também podem ser autores, por vezes, do crime de posse de entorpecente para uso próprio. Recurso defensivo provido, prejudicado o recurso do Ministério Público. Aplicação do artigo 383 § 1º do CPP." (TJ-SP - APR: 15000609320188260574 SP 1500060-93.2018.8.26.0574, Relator: Hermann Herschander, Data de Julgamento: 14/09/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/09/2021)

Assim, acolho o pleito da defesa para desclassificar a conduta cometida pela acusada para o tipo previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.340/2006.

Quanto ao dinheiro apreendido nos autos, não mais interessam ao processo criminal, na forma do disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, razão pela qual autorizo a restituição ao réu, que poderá constituir procurador com poderes específicos para efetuar a retirada.

Passo a dosar a pena do acusado.

Tendo em conta a condição de usuário do acusado e considerando se tratar de reincidente específico (processo nº 0001095-44.2018.8.26.0581), entendo que as penas mais adequadas entre aquelas previstas no artigo 28, da Lei 11.343/2006 são as de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo para dependentes químicos de substâncias entorpecentes, a ser cumprido no CAPS de seu domicílio, e prestação de serviços à comunidade, ambas a serem cumpridas durante o período de 08 meses.

Destaco que a advertência é medida insuficiente ante o histórico de dependência do acusado.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para condenar o réu GILMAR SILVA DA CRUZ, qualificado nos autos, por incurso no art. 28, "caput", incisos II e II, e § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo para dependentes químicos de substâncias entorpecentes, a ser cumprido no CAPS, e prestação de serviços à comunidade, ambas pelo período de 8 meses.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se o necessário.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Proceda-se em relação às drogas apreendidas conforme o disposto no art. 72, LD, no que ainda couber.

Atendam-se às demais disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, no que for pertinente.

Sentença registrada digitalmente.

Publique-se. Intimem-se.

São Manuel, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA